

1500148-38.2022.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... se falar em condenação pelo crime de tráfico, todavia, justifica-se a desclassificação para o art. 28, da lei 11.343/06.

Pode-se aplicar a desclassificação do crime de tráfico para uso quando o conjunto probatório deixa dúvidas quanto à existência de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

No caso em tela, o acusado foi preso portando pequena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz2@tjsp.jus.br

1500148-38.2022.8.26.0592 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 21 de julho de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500148-38.2022.8.26.0592

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELITON HENRIQUE LOPES PEREIRA

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 119/122) em face de Eliton Henrique Lopes Pereira pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 21 de abril de 2022, por volta das 15:30 horas, na rua Guido Siena, próximo à esquina com a rua Israel Tiozzi, Conjunto Habitacional Alberto Lang, nesta cidade e Comarca, ELITON HENRIQUE LOPES PEREIRA, qualificado a fls. 04, transportava e trazia consigo 99,75 gramas da droga "maconha", para entrega a consumo, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e laudos periciais de fls. 12/14 e 103/105.

Apurou-se que, no dia, hora e local dos fatos, durante fiscalização rotineira, policiais militares avistaram o denunciado caminhando em via pública com uma sacola em suas mãos, o qual, ao notar a presença da viatura policial mudou rapidamente de direção, tirando algo do bolso e dispensando-o ao solo, pelo que foi abordado. Em revista pessoal, com o denunciado foi encontrada a quantia de R\$20,00, e no interior da sacola que trazia consigo havia uma balança de precisão.

Os policiais ainda recolheram o objeto jogado ao chão pelo denunciado e constatou-se tratar-se de um tablete de maconha, droga retro mencionada.

O denunciado admitiu a propriedade da droga, conquanto tenha dito que seria para consumo pessoal, assertiva incongruente com a quantidade e possibilidade de resultar em inúmeros cigarros para uso.

Então, o denunciado, juntamente com a droga, o dinheiro e a balança de precisão apreendidos, foi encaminhado à Unidade Policial para as providências cabíveis.

Assim, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, a forma como estava embalada, o dinheiro e a balança de precisão apreendidos, sendo certo que sabidamente referido objeto é geralmente utilizado na mercancia de entorpecente, as condições em que se deram os fatos, bem como da conduta social do denunciado, torna-se evidente que o entorpecente apreendido tinha o comércio como destino."

A denúncia foi recebida em 24/06/2022 (fls. 153).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 143/151). Não foi concedida absolvição sumária (fls. 153).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as testemunhas, sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela desclassificação.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 08/10); auto de prisão em flagrante (fls. 01); auto de apreensão (fls. 06/07); laudo pericial (fls. 12/14); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral.

A testemunha Adriano Rogério de Souza, Polícia Militar em seu depoimento judicial, relatou "que estava de serviço nos dias dos fatos com o cabo Edmilson, que avistaram o indivíduo caminhando pela via com uma sacola, que o réu quando viu a polícia mudou de direção indo para a traseira de um caminhão, que arremessou alguma coisa no canteiro da empresa Granol, que foi dado a ordem de parada, que foi encontrado uma quantia de 20,00 reais e na sacola uma balança de precisão, que indagado sobre o que ele arremessou ele negou que tinha jogado, que depois de uma varredura para encontrar o que foi jogado, foi localizado um tijolo de maconha ele confessou que o tablete de maconha que ele tinha jogado era dele, foi levado a casa do seu tio Valdir, que quando chegando lá foi feito uma vistoria no quarto dele localizando duas munições, que foi dado a voz de prisão e levado a delegacia, que depois de localizado a droga o réu confessou que era para uso próprio, que foi localizado duas munições calibre 38".

A testemunha Edmilson Cesar Manso, Polícia Militar em seu depoimento judicial, relatou "que estavam em patrulhamento pelo bairro Alberto Lange, que quando o indivíduo viu a polícia mudou de direção indo para trás de um caminhão, e jogando um objeto fora no terreno da empresa Granol, que foi realizada a abordagem no indivíduo foi localizado uma sacola com uma balança de precisão, após procurarem o que o indivíduo jogou no terreno foi localizado um tijolo de maconha, que no início negou que a droga era dele mas depois assumiu que a droga era dele".

Interrogado judicialmente, o réu confessou que a droga era para uso pessoal. Disse que a droga era para uso próprio, que é usuário de maconha, que jogou fora porque estava assustado quando viu a polícia, que a maconha era dele mas a balança de precisão era da sua avó, estava levando a balança para a casa do seu primo, que usou a balança para cortar a maconha para uso próprio, que lembra que era 95 gramas, que tava com essa quantidade para fumar, que estava indo da casa dele para a casa do primo dele, que comprou a droga na vila esperança, que a balança estava na sua casa, que pesou a droga, que levou a balança para o local onde ele comprou, que o dinheiro era dele fruto do serviço, que tinha acabado de chegar do serviço, é usuário a 15 anos, que nunca foi internado".

Razão assiste à Defesa.

Do percuciente do quadro probatório, infere-se que a conduta do acusado melhor se amolda ao delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, inexistindo prova segura e concludente da finalidade da traficância, devendo vigorar, no caso, o princípio do in dubio pro reo. Com efeito, o conjunto probatório é insuficiente para reconhecer a finalidade da mercancia.

A materialidade do delito restou comprovada, mas constatada a ausência de provas quanto a versão acusatória, que se contrapõe com a firme alegação da processada no sentido de que a droga servia ao seu consumo, não há que se falar em condenação pelo crime de tráfico, todavia, justifica-se a desclassificação para o art. 28, da lei 11.343/06.

Pode-se aplicar a desclassificação do crime de tráfico para uso quando o conjunto probatório deixa dúvidas quanto à existência de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

No caso em tela, o acusado foi preso portando pequena quantidade de maconha e confessou que seria para uso pessoal. Justificou a presença da balança e somente foi encontrada uma nota de R\$20,00 que teria sido pagamento do trabalho realizado. Portanto, não há nenhum elemento que indique que o réu praticava o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Não se pode olvidar que ao decreto condenatório não basta um mera probabilidade, mas um juízo de certeza, demandando-se provas seguras ou sérios indícios acerca da autoria delitiva. De fato, não restou provada nos autos a prática da mercancia ilícita. Circunstância que, aliada à negativa da traficância da acusada desde a fase policial, amparada pelas demais provas, torna impossível o decreto condenatório baseado em inferências e suposições para a imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reprisa-se, ainda, que o delito de tráfico de drogas é geralmente perpetrado na clandestinidade, devendo a autoridade policial e seus agentes desenvolver as ações necessárias à constatação e recolhimento de provas que possam sustentar uma condenação, sendo certo que na ausência de caderno probatório substancial, melhor é adotar o princípio do in dubio pro reo, preservando-se as garantias constitucionais insertas nos princípios da presunção de inocência e da não culpabilidade. Ademais, é cediço que a quantidade de substância entorpecente ilícita apreendida pode ser considerada para a formação do juízo de valor quanto à existência ou não do crime de tráfico, já que muitas vezes não se consegue flagrar o ato mercantil. Contudo, no caso em tela, a pequena quantidade de substância entorpecente encontrada (95,36g de maconha), a pouca quantidade de dinheiro em espécie encontrada (R\$ 25,00), e a falta de variedade, autoriza crer que a versão exculpatória do acusado é verossímil, consubstanciada na tese de que a droga seria para consumo próprio.

Por certo, a linha que diferencia as condutas previstas nos artigos 28 e 33 da Lei 11.343/2006 é tênue. Nesse contexto, o legislador, ao redigir o § 2º do retromencionado art. 28, indicou ao intérprete critérios objetivos e subjetivos para determinar, no caso concreto, a correta subsunção do comportamento do agente: "§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Repisa-se, não foi encontrada nenhuma outra prova (anotações referentes ao tráfico, grande quantidade de dinheiro em espécie e em notas pequenas, testemunhas oculares da venda de drogas, prisão em flagrante durante a venda etc.) que pudesse corroborar a imputação pela prática do tráfico de drogas pela acusada.

Por fim, necessário esclarecer: "vigora no sistema processual penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar" (STJ, HC 68.840/BA, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 28-04-2015).

Por outro lado, não há como ignorar que a materialidade do delito ficou comprovada através dos autos de exibição e apreensão, do laudo de constatação, bem como do laudo de exame químico toxicológico. Porém, diante do escasso conjunto probatório

reunido nos autos, verifica-se que permanece séria dúvida de que a réu é efetivamente traficante e que as poucas porções encontradas em seu poder destinavam-se ao comércio ilícito.

Vejamos o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci (Leis penais e processuais penais comentadas – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“As cinco condutas previstas no art. 28 (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo) também fazem parte do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76). Entretanto, neste último caso, cuida-se de tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, gerando pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e multa elevada, enquanto o outro não constitui delito equiparado a hediondo, sem a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade, somente porque a finalidade do agente é o consumo pessoal. Em face disso, muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76). Por outro lado, inúmeros usuários acabam, injustamente, autuados com base no art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76), quando merecem a desclassificação para o art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76). Essa situação não comporta resolução teórica única, pois depende do caso concreto e das provas produzidas em cada processo. Porém, tem sido referencial para a jurisprudência brasileira a quantidade da droga apreendida, os antecedentes criminais do agente, quando voltados ao tráfico, bem como a busca do caráter de mercancia. Quem traz consigo grande quantidade, já foi condenado anteriormente por tráfico e está em busca de comercialização do entorpecente é, com imensa probabilidade, traficante (art. 33). No entanto, aquele que possui pequena quantidade, nunca foi antes condenado por delito relativo a tóxicos, bem como não está comercializando a droga é, provavelmente, um usuário (art. 28).

Não havendo provas de efetiva realização de atos que o réu tinha a intenção de comercializar a substância entorpecente, não há que se falar em crime de tráfico de drogas. Assim, devida, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso.

Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 15006112120188260559 SP 1500611-21.2018.8.26.0559, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 30/04/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021; APL: 00425368720148260114 SP 0042536-87.2014.8.26.0114, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 07/03/2017, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2017; APR: 15117210620198260228 SP 1511721-06.2019.8.26.0228, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 30/04/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021; APR: 15007932920198260411 SP 1500793-29.2019.8.26.0411, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 16/04/2021, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/04/2021.

Com relação à medida aplicada, verifico que o réu está preso desde o dia 21/04/2022, ou seja, totalizando 3 meses. Ademais, as medias previstas no artigo 28 da Lei de Drogas somente podem ser aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses, em caso de reincidência, conforme § 4º do referido artigo.

Destarte, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei de Drogas, aplico ao réu a medida educativa de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas, atendendo as circunstâncias do caso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para DESCLASSIFICAR a imputação, do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para o art. 28, caput, da Lei 11.343/06, e, em consequência, aplico ao réu a medida educativa de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas.

Fica o sentenciado advertido sobre os efeitos das drogas, no presente ato. Assim, julgo extinta a pena pelo cumprimento.

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA. Com efeito, ausentes os seus requisitos. Expeça-se alvará de soltura colocando-se o réu em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

Oficie-se ao IIRGD.

Sem custas.

P.R.I.

Osvaldo Cruz, 21 de julho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA